

再論臺灣法律史^{*}

—— 對評論人的回應

王泰升^{**}

目 次

壹、共通的部分
貳、邱文部分
參、陳文部分

肆、顏文部分
伍、結語：期待其他的評論

衷心感謝《中研院法學期刊》提供這個意見交流平臺，與三位評論人相識多年，難得有這個機會，可以釐清我的基本立場與想法。在獲得這些評論之後，更能體會孔子所說，益友有三，「友直、友諒、友多聞」。作為一個學術會議主題之引言的〈臺灣法律史的提出及學科化〉（以下稱「拙文」）一文，篇幅相當有限，故特別在第一段末表示「各項說法之較詳細的學術論證，仍請另外參閱拙作各文」，尤其是參閱用以闡述最新看法的近作；但對讀者而言，

* 投稿日：2019年5月14日；接受刊登日：2019年5月14日。〔責任校對：黃品瑜〕。

本回應文曾請2017年11月30日在「法律與歷史的交匯：台灣法律史二十年」國際學術會上，聽過我發表〈台灣法律史的提出及學科化〉一文的研究同好，閱讀初稿並惠賜卓見。其中黃丞儀教授提供不少可更清楚表達拙意的文字建議，殊樂於採用，並特別在此誌謝。惟本回應文的一切文責，均由我自己承擔。此外，對於編務人員的辛勞，亦表示最高的敬意與謝意。

** 國立臺灣大學法律學院台大講座教授、中央研究院臺灣史研究所暨法律學研究所合聘研究員。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/40616091.pdf>。



這似乎是過於嚴苛的期待。所幸藉由這篇回應之文，可再申述所持見解，而與不同學術專長者交流。在此原則上仍以三位評論人可參閱之我的既有論著為基礎，對評論文進行包括澄清本意在內的回應。此亦是延續拙文在「緒言」所言，擬藉由剖析「個人研究史」，帶出事關「整個學界的發展」的學科化議題。

寫法上是從披露個人的知識建構歷程切入，當然就不會是典型的學術論文撰寫模式，不然參考文獻大多數是撰文者自己的作品還像話嗎？這項披露是為了闡釋拙文第二段所言：「沒有我這個人，也會有另一個人，在同樣的歷史時刻，探究臺灣法律史。」何以故？20餘年來，作為某個特定研究取徑的「代言人」，深深感受到許多人係將關注點，不論褒貶，都聚焦於我這個人，而不是這個研究取徑。誠然確實有一個「拿著鋤頭的園丁」不斷地耕耘，但存在著這樣的個人，乃特定時勢以及臺灣社會特定需求底下的必然。因此應跳脫對「代言人」個人的喜惡，而仔細思辨作為「當事者」的這個研究取徑，應否在當今臺灣知識界的研究與教學上，擁有一定的身分與地位，亦即拙文所稱的「學科化」，姑且不論讀者或評論者自己有意願或時間進行臺灣法律史研究。倘若能順利地學科化，將不會再有單一作者獨占多數論著、這種草創時期的不正常現象。

以下先處理評論人均提及的議題，再分別就邱澎生之文（以下稱「邱文」，在此及以下均省略「教授」之敬稱），陳惠馨之文（以下稱「陳文」），以及顏厥安之文（以下稱「顏文」）個別提及者進行回應。

壹、共通的部分

一、臺灣及其法律史的意義：兼論與中華民國史及中國史的關係

關於臺灣法律史的意義，陳文點出一個核心問題：「臺灣做為地理名稱或者政治體」，並指出「中國」、「朝鮮」等詞亦有雙重意義，邱文也認為拙文對何謂「中國」沒說清楚。在此先談「臺灣」的意涵。欲提出一個研究及教學的領域，須配合國內外學術界的一般理解，故可從我最初在國內外學界對「臺灣」及其法律史所做的定義說起。1997年在英語世界著名的Butterworths出版社出版的「亞洲法律體系」一書，以專章說明臺灣（不使用「中華民國」之國名）的法律體系（legal system）時，曾表示臺灣一詞係指臺灣本島、澎湖群島，以及附屬島嶼。按澎湖與臺灣本土（Taiwan proper）在歷史上長期被視為一體，附屬島嶼則包括如臺灣本島邊緣的綠島等「地理上附屬島嶼」，以及金門、馬祖等「政治上附屬島嶼」，雖金馬位於中國大陸的邊緣而可能被質疑，但其從1949年迄今一直與臺灣本島同在一個政府管轄底下¹。另一篇1999年以英文在澳洲期刊發表、探究近代西方法如何影響在臺灣的華人之法律史論文，第一個標題就是「關於臺灣之意涵的說明」。對臺灣一詞，採取與前揭1997年之文同樣的定義，並表示「將金馬納為臺灣的一部分雖有爭議，但從人民、而非土地的觀點，將半個世紀以來與臺灣居民頻繁往來而滋生共同感的金馬人民，排除於臺灣共同體（Taiwanese community）之外是不適當的。〔按：原係英文〕」² 換言之，若「臺灣」僅僅是地理名詞，恐不能涵蓋金門、馬祖兩群

1 Tay-sheng Wang, *Chapter 4: Taiwan, in ASIAN LEGAL SYSTEMS: LAW, SOCIETY AND PLURALISM IN EAST ASIA* 124, 125 (Poh-Ling Tan ed., 1997).

2 Tay-sheng Wang, *The Impact of Modern Western Law on the Chinese in Taiwan*, 1 AUSTL. J. ASIAN L. 194, 194 (Sean Cooney trans., 1999).

島，但是歷史論述是為當代人民而存在的，故應將金馬人民納入作為一個**共同體**的臺灣。臺灣不只是地理名詞！

如同陳文所述、以當代作為現代國家的德國的地理空間來論述歷史，臺灣法律史是以當今事實上作為一個現代國家，亦即**政治共同體**的臺灣，作為地理空間（土地）的**範圍**，論述其上曾經存在的人、事、時、地、物。2001年以華文出版第一本臺灣法律史的教科書，即表示：「在此是以現今台灣共同體的地理空間，來定義歷史」³，2009年的第3版再加一句：「台灣共同體係指在目前尚稱『中華民國』的政府及其法律管轄的地域內共同生活的群體，該地域包括了台灣本島以及地理上或政治上附屬島嶼，亦即所謂『台澎金馬』」⁴而且，不論2001年或2009年版，都緊接著說：「如圖1-1所示，在今日台灣共同體賴以生存的地理空間上，於不同的歷史時間裡，存在著統治地域也不盡相同的數個政權（圖1-1之2到7），且族群的組成亦有別」⁵」

拙文指出，臺灣自1895年（金馬為例外）迄今，除1945-1949年外，並不為作為現代國家的中國（這點待後詳論）所統治，而是自為一個政治共同體。陳文認為我對此沒說清楚，但拙文在這一段的註12，已有意交代相關的背景知識了。亦即指出，**今之臺灣共同體**所在的**土地**，最早居住著原住民族各部落，臺灣本島則被西方人稱為「福爾摩沙」；17世紀有一小部分土地，成為荷蘭人經營的殖民地，該地域接著由西方人認為是獨立王國的漢人鄭家政權統治。再來，逐漸擴大為已過半的土地，作為清朝的一或多個府（1684-1887年）或一個省（1887-1895年）。但是除了金馬以外所有的土地，從1895年起作為日本帝國內一個獨自的法域/殖民地，臺灣人

3 王泰升，台灣法律史概論，頁6（2001年）。

4 王泰升，台灣法律史概論，3版，頁5（2009年）。

5 王泰升（註3），頁6；王泰升（註4），頁5。

意識亦自此滋生。1945-1949年曾短暫地作為屬現代國家的中國的一個省。然而從1949年起，出現一個以臺澎金馬為領土，居住其上者為人民，並組成主權政府之以「中華民國」為國號的國家。因此在不同的歷史時間，今稱臺灣的這塊土地上，曾有一個以上的政治共同體。顏文謂臺灣在19世紀60年代，「毋寧更像是漢人與原住民『分治』的狀態」，所指的大概就是當時除了經由清朝的臺灣府所形塑的政治共同體之外，還有許多漢人稱為「生番」的原住民族的部落，可整個視為另一個政治共同體。須待日治後、約1915年時臺灣總督府得以實質統治絕大多數高山族原住民族，整個臺灣成為單一的政治共同體。此後一直延續至今。

由於金馬以外的臺灣，從1895年至今的2019年，已有120年，未被作為現代國家的中國所統治，故沒辦法從中國史了解臺灣的法律發展歷程。在此當然涉及什麼是「中國」，所以在拙文註12提供了一些基礎知識，指出：「當今所稱的中國、日本、韓國，都是在19世紀，依源自西方的國際法，各國應平等往來、締約等概念，所產生的『國族國家』（在聯合國體系內，中國指中華人民共和國，韓國則有兩個會員國），有別於東亞社會在此之前，以統治中原郡縣的皇帝為中心、周邊受冊封之蠻夷君長須向皇帝朝貢的『天朝』與『王國』之關係。」由於已各為現代國家，故追溯今之中國這塊土地上曾發生的歷史即稱「中國史」，追溯今之韓國這塊土地上曾發生的歷史則為「韓國史」。正是在這個脈絡底下，拙文表示「臺灣與中國……一百多年來均不在同一國家法秩序底下，並以獨立的法院體系建構一個特定的法域（jurisdiction）……，為了解臺灣的法律發展，須從向來被中國國族主義放在作為現代主權國家的中國之內，移置於整個共享傳統中原法律文明、屬於漢字文化圈的東亞社會當中，自為一個政治共同體。」

拙文擬呈現的是一個知識演進的過程，故1995年所劃的拙文圖1及其說明，「僅是透過較消極的『去中國中心化』，而肯認臺灣在

法律史上……具有主體的地位」，尚非最終的見解。詳言之，以現代國族國家為基準的國別史，有時不易表達歷史的真實面貌。例如前述中國史、韓國史的分際看似清楚，但首都位於今之中國境內、昔日朝鮮族所建之天朝秩序下周邊政治共同體的歷史，又該屬於哪一國歷史呢？就如同孔子是哪一國人？「魯國人」也，當時根本沒有今之中國或韓國的概念，故嚴格來講應屬東亞社會/漢字文化圈的歷史。不過，若已特別交代今昔之別，倒也可以各自寫入以中國為中心/主體的中國史，以及以韓國為中心/主體的韓國史。因此仍可以有國別史，但不應以之為唯一且排他。例如就作為天朝的清朝曾經統治過臺灣（不含高山族原住民族部落）212年，可各自寫入以臺灣為中心/主體的臺灣史，以及以中國為中心/主體的中國史。同樣的，民國時代中國的歷史也可各自寫入臺灣史、中國史⁶。正是在這樣的認知下，我表示：中國法只是臺灣法的一部分但很重要⁷、臺灣法律文化當中的中國因素⁸、去中國中心化但不能去中國化⁹。早在2006年，我就曾在中央研究院法律學研究所主持過「民國時代中國法之研究」，劉恆奴執行該項研究中有關司法領域的子計畫，即翔實地闡釋戰前中國的「黨化司法」經驗，如何主導或影響戰後臺灣的司法¹⁰。此處的「中國」，都可以更換為「日本」，我亦曾以日文表述該論點¹¹。當然亦可以不被國族國家的框架所限，

6 其詳，請參見王泰升，國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁73-77（2009年）。

7 王泰升（註3），頁11；王泰升（註4），頁9；王泰升，台灣法律史概論，5版，頁9（2017年）（以下簡稱：王泰升，台灣法律史概論，5版）。

8 王泰升，臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起，政大法學評論，142期，頁3（2015年）。

9 王泰升，清末及民國時代中國與西式法院的初次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁112（2007年）。

10 參見劉恆奴，戰後臺灣的「黨化司法」——1990年代之前國民黨對司法人事的制度性掌控及其後續影響，中研院法學期刊，24期，頁1-86（2019年）。

11 王泰升，台灣法律文化中的日本因素：以司法層面為例，政大法學評論，95期，頁58、61（2007年）。該文指出：「這項文化創新，因來自受日本統治，故可稱之為『日本因素』，然其中有一部分，就其實質而謂為『西方因素』亦無

書寫不同於中國史之以滿族為中心的滿族史，不同於臺灣史之以原住民族為中心的原住民史。

就「臺灣」的定義，其實係跟隨著「了解周遭法律生活」、「運用於法制訂及法適用」等臺灣法律史認識目的走。如顏文所述，顏厥安2000年時曾就臺灣法律史研究做了幾點提示；其中之一是，對我以1949年迄今為事實上國家，作為建立臺灣法律史的理由，指出「國家主體性之色彩較強」¹²。這是我表達得不夠清晰所致，因此2001年寫教科書時，在第一章第一段就表明反對以「塑造國民」為目的的「國家史」，而是以了解周遭的生活環境，作為學習歷史的目的，並在談及「臺灣史觀」時說清楚：「作為主體的台灣，非指某特定的政權或國家，而是指由居住其上的人民所組成的一個共同體」¹³。按「共同體」一詞乃是翻譯自英文的「community」，但其似乎沒辦法完整地傳達英文的原意，故在「政治共同體」之外，有時講「地域社會」或「生活共同體」¹⁴；無論何者，所強調的核心意義是，因生活在同一個團體/社區/共同體，所有成員的利害及命運是一致的。且由於2010年提出的「歷史思維法學」，期待臺灣法律史的知識，能夠運用於當今行政、立法上的制訂法令，以及司法上的解釋適用法律，故所觀察的對象，須與法律將施行或適用之法域，亦即中華民國法秩序實際上規範效力所及的地域，以及所管轄的人民相一致。從臺灣史的觀點，這是「臺灣繼受中華民國法」的

不可。」王泰升，同本註，頁61。亦以「日本元素」為書名一部分，向日語世界的讀者，表達如此定位日本法對臺灣法律史的意義，參見王泰升著，鈴木賢、松田惠美子、西英昭等譯，台灣法における日本の要素（2014年）。

12 顏厥安，法律史研究中的理論問題——評王泰升：《台灣法律史的建立》〈導論〉部分，收於：王泰升、沈靜萍、陳鈺雄編，台灣法律史研究的方法，頁25（2000年）。

13 王泰升（註3），頁3、6。

14 例如，王泰升，臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，頁78、121（2015年）。

結果¹⁵。

中華民國史原屬中國史一支，1945年方與臺灣（不含金馬）發生關係，但1949年起迄今已與臺灣史合一。雖力倡臺灣法律史，我也曾參與以「慶祝中華民國建國一百年」為旨趣的中華民國史的撰寫，並以如下這段話定義「中華民國史」：

在此係以1911年成立之「中華民國」此一國家組織體的發展，作為歷史論述的對象，而以「法學」為歷史探究的核心與議題。惟國家僅是法政制度上的一種形式，其實際作為來自組成國民及運作政府的這些人，故所謂「中華民國法學史」，毋寧就是關於組成及運作「中華民國」此國家組織體的人們，在法學上種種表現的歷史¹⁶。

按自居天朝的清朝因鴉片戰爭戰敗，1842年與英國簽訂和約而進入「條約體制」，成為現代主權國家的中國的一個政府；雖清朝非漢人所建立，但歷來國際社會認為統治中國內地（指核心地帶，亦稱「中國本土」，China proper）/中國大陸的該政治組織體就是所稱的「中國」。1911年出現「中華民國」臨時政府，隔年在中國

¹⁵ 最近曾詳細說明「臺灣繼受中華民國法」的概念，引用其原文如下：「從臺灣史而言，作為臺灣現行國家實證法的中華民國法制，在1945年之前不曾施行於臺灣（但金門馬祖為例外），在1949年之後卻只施行於臺灣（臺澎金馬），不再施行於作為原產地的中國。由於臺灣在1949年年底之後，已因存在一個可承擔主權政府功能的『中華民國』中央政府，而事實上成為一個國家，也開啟了『臺灣繼受中華民國法』的進程。……臺灣政治共同體於1949年，將原以中國為施行地域、但嗣後已未施行於中國的中華民國法制，接納為一個（事實上）國家的實證法（positive law, state law），故可稱此動作為『繼受』。」王泰升（註14），頁77。在現今中華民國法制上，只有「臺灣地區人民」，亦即實際上居住在臺灣（臺澎金馬）的人民，才是稱為「中華民國」的臺灣這個事實上國家的國民；若一定時間以上居住在中國大陸（不含金馬）而具有稱為「中華人民共和國」的中國的戶籍，即屬於法制上的「大陸地區人民」，實際上失去身為臺灣國民的權利義務，亦即在臺灣沒有參政權，也不曾有服兵役義務。王泰升（註14），頁99。

¹⁶ 王泰升，中華民國百年法學發展史，收於：國立政治大學人文中心編，中華民國發展史（一）：學術發展（上冊），頁287（2011年）。

這個國家發生了政府繼承，由中華民國政府繼承清朝政府，這是前述國家史概念下中國史的大事。中國的中華民國政府（當中稱「國民政府」者）於1945年10月25日，代表盟軍軍事接收中國（由清朝政府）50年前依條約讓與主權給日本的臺澎，稱為「中華民國」的國家組織體從此支配居住於臺澎這塊土地的人民，故中華民國史與臺灣史首次有了交集。1949年10月1日建立的「中華人民共和國政府」，取代中華民國政府而為中國這個國家的新政府，並經聯合國1971年2758號決議確認中國於1949年已發生的政府繼承，但該決議並未言及日本已於1952年依舊金山和約所放棄的臺灣主權¹⁷。自1949年12月9日中華民國政府的行政院在臺灣重新開張起，組成及運作稱為「中華民國」的國家組織體的人，以及該國家組織體所管轄的人民，皆是在臺灣（臺澎金馬）進行各項政經社文的活動，是以中華民國史已與臺灣史合而為一。惟作為規範事實的國內法上宣稱，在臺灣目前國號〔按：若國號改變，亦不影響國家的同一性〕為「中華民國」的國家組織體，以憲法宣稱其領土包括係由中華人民共和國政府統治的中國（稱「大陸地區」），中國的中華人民共和國政府則宣稱中國擁有臺灣主權¹⁸。

17 聯合國1971年2758號決議案決定：「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」該決議雖不提及臺灣的國際地位，但中國一直宣稱其擁有臺灣主權。國際社會對此的反應，以美國為例，在1972年的「中美聯合上海公報」上，「美國認識到，在臺灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，臺灣是中國的一部份。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決臺灣問題的關心。」在此美方「認識到」，而非「承認」中方立場，且所認識的是：臺海兩邊的「中國人」都認為臺灣是中國一部分。純從其文字而言，若臺海有一邊不再表示自己是「中國人」，即另當別論吧。參見王泰升（註14），頁82-83。

18 在此係敘述政治事實及規範事實，而不處理國際法規範上應如何透過解釋適用定位中國與臺灣之關係。這是法律史研究者經常、但不必然採取的作法。例如我曾在最近出版的一本學術專書中表示：「本於對這些經驗事實的認識，臺灣人民及臺灣法學界才能夠進一步思索：未來應該延續此一方向或者應有所調整？應以引進這些國家的法律或法理論作為法律現代化的唯一途徑嗎？惟本書係定位為法律社會史，亦即法經驗事實之研究，故將不處理這些關於應然面的

最近曾在幾個與不同學術背景的人談臺灣法律史的場合¹⁹，以臺灣從1895年改由日本統治，及1911年中國史上出現中華民國作為開端，劃出「臺灣與中國法律發展軸線示意圖」（如下圖1）。藉由圖上這幾個時間點想表述的是，臺灣的法律現代化始自脫離中國統治的日治時期，臺灣經過20餘年過渡後於1923年施行現代民法典；中國則在經歷民初動盪後的1929年，才公布現代民法典。原與臺灣史處於平行狀態的中華民國史，在1945年橫切入臺灣史的軸線，但中華民國史在中國史的軸線上卻只到1949年為止。這項民國中國（在中國的中華民國）的法律經驗，將欠缺土地調查、不重視法治等「法社會」留給中國，直到1978年中國才擬恢復現代法制。離開中國史之後的中華民國史（在臺灣的中華民國），卻從1949年起與臺灣史合一。民國中國的民法典等「法規範」則留給臺灣，並隨著戰後臺灣的政經社文大環境而被增刪調整，進行了臺灣化²⁰，1991年終結非常法制，2000年首次政黨輪替。從漢學研究的角度，此示意圖從歷史發展軌跡之有別，闡釋了當今臺海兩岸兩個以華人為多數（及少數不屬於漢族者）的國家，為什麼法律現狀有所不同。

議題。」王泰升（註14），頁177。

19 王泰升，具有「彈性」的人文思考，中央研究院、國立清華大學、國立交通大學新進研究人員交流會，中央研究院主辦（2017年6月9-10日）；王泰升，換個角度看台灣的法律史，國立臺灣大學跨領域交流會（第17次），國立臺灣大學法律學院暨社會科學院主辦（2017年12月26日）；王泰升，人文社會取向的法學，交大法學暨跨領域講座，國立交通大學科技法律學院主辦（2018年4月18日），再發表於2018年科技部法學研習營，中央研究院法律學研究所、國立中興大學法律學系主辦（2018年11月30日）；王泰升，換個角度看台灣的法律史：從台灣學出發，「台灣學在台大」演講，國立臺灣大學臺灣文學研究所暨臺灣研究學程主辦（2018年5月18日）。

20 這個「臺灣化」的概念，參見王泰升（註14），頁121-123。

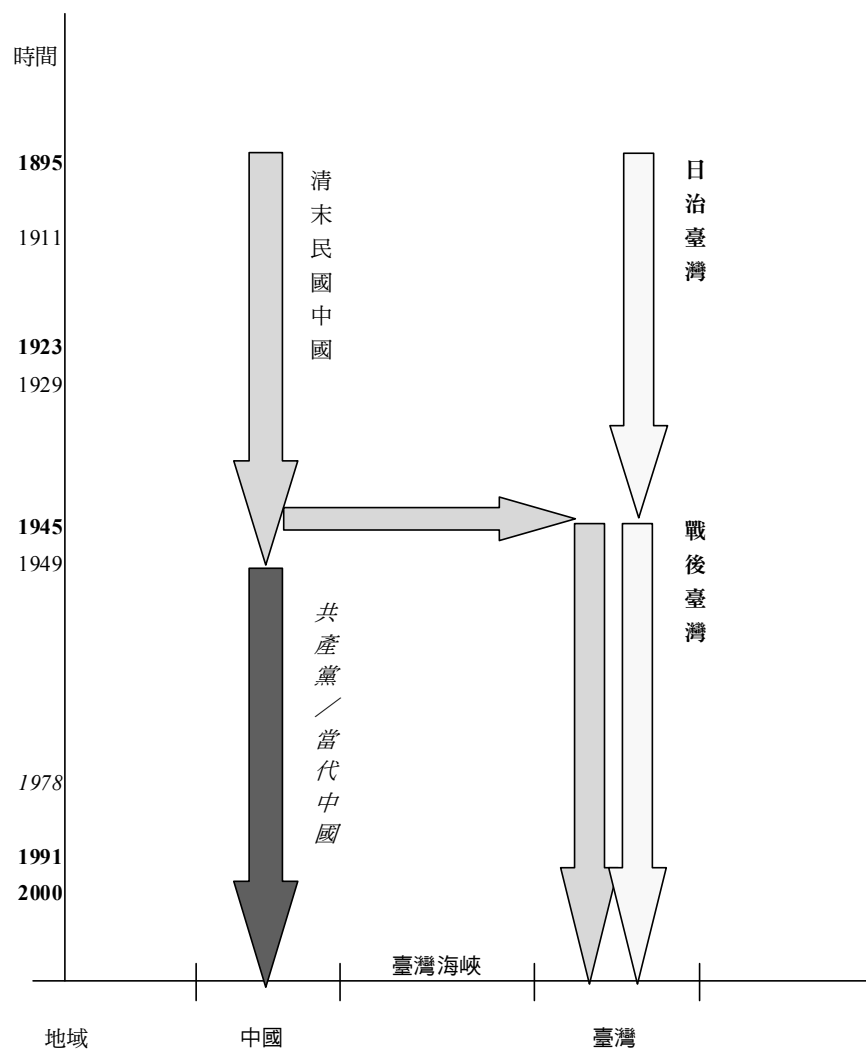


圖1 臺灣與中國兩條法律發展軸線示意圖

資料來源：作者繪製。

或許可返璞歸真地為作為學科的「臺灣法律史」下個定義：凡是以過去曾發生在今之臺灣（臺澎金馬）這塊土地上，與今之法律相關（包括不具現代性的法制）的經驗事實，作為主要的觀察或論述的對象，均屬之。所謂「主要的」，係指「以臺灣為中心」（Taiwan-centered），亦即「作為主體」，乃相對於以觀察或論述其他群體的歷史為主要目的而附隨提及發生於臺灣者。在此定義下，不問觀察者自身是什麼國籍、族群、職業、學科訓練²¹，也不問以什麼意識型態、理論、學說等作為詮釋歷史的依據²²。這樣的「法律史」，欲了解與法律相關的人、事、時、地、物的歷史。而以臺灣法律史作為研究及教學上的一個領域，就是拙文主張的「學科化」，不問課程名稱是什麼²³。

二、歷史分期問題

關於歷史分期，拙文著重於描述我個人對此議題的思考過程，對最終形成的見解顯然交代得太少，僅在拙文註28表示對之已於另

21 拙文的註20已提到：「也有外國學者為了認識臺灣，而在研究上以臺灣為中心」，彼等所為者即臺灣法律史之研究，稍後將會介紹這些研究成果。事實上也有好幾位在臺灣唸書的日本學生，曾寫過關於臺灣法律史的博碩士論文。

22 拙文在註17已表示：「戰後臺灣的學校教育從小到大一直灌輸的『中華民族』，實即中國國族之意」。黃靜嘉曾本於「殖民地人民對殖民地統治的抗爭，為中華民族抗日鬥爭之一環」的中國國族主義立場，詮釋臺灣在日治時期的法律發展，其所撰寫的專書亦屬臺灣法律史的作品。我在臺大講授臺灣法律史時，一直將該書列入「參考書籍」。黃靜嘉，春帆樓下晚濤急：日本對臺灣殖民統治及其影響，頁458（2002年）。

23 黃丞儀閱讀本回應文初稿時，認為此處的「學科化」可定義為：「在知識體系上針對具有獨特、可區分的研究對象，以科學（含社會科學）方法進行研究，而其研究成果在知識意義上具有特定之貢獻，從而可與其他學科領域區隔開來。在知識系譜上，此一研究成果的累積有助於我們對於該研究對象產生科學式理解，漸漸成為獨立的學科，此一知識產生與獨立的過程即為學科化。」此外，陳文認為我強調必須課程名稱為「台灣法律史」才是臺灣法律史，似有誤會。如拙文所示，臺大法律系以講授臺灣法律發展為軸線的必修課，是以「法律史」為課程名稱，而無「臺灣」兩字。我在臺大向外界公開的「開放式課程」，因讀者不一定是專研臺灣法律的臺灣法律系學生，為了有清晰的定位，在課程名稱上標示「臺灣」，其全名為「台灣法律史：從前不教的一門課」。

文詳述。容我先補述在此所稱之「另文」所下的標題：「依特定關心點而為『分期』」、「1. 依政權或國家的變動」、「2. 依法律文明的類型」、「3. 依法律規範的內容或特性」。該文並在最後一段謂：「總之，研究者可依自己選定的法律主題或法律領域，考察其在臺灣的發展過程，時間點也可以做一定的限定；或者不以整個臺灣，而是以某縣市或特定區域為範圍，觀察人民法律生活的變遷；再依各別的歷史發展軌跡，訂出最貼切的分期。²⁴」不過我仍認為，整個臺灣法律發展的歷史，在沒有特別要採取某特定觀點的情形下，最一般而基本的分期，係拙文根據**政權或國家**所做的分期，亦即：原住民族自治時期、荷西統治時期、鄭治時期、清治時期、日治時期、戰後時期或中華民國時期。「國治時期」是本於現代民主國家才有的政黨輪替係發生於2000年，並以國民黨政權持續一黨執政55年（1945-2000年）為特色而做分類的一個時期，嚴格來講還不算「一般而基本」的分期方式。

對於上揭一般而基本的分期方式，顏文的質疑是：「比較像是政治史而非法律史的分期」。固然政權或國家都是政治團體，故可謂為政治史的分期。但在探究憲法史時，有必要討論政權或國家屬性之為獨裁或民主，在探究一般人的法律生活時，亦有必要討論不同政權或國家的司法制度及文化，是以政治史與法律史不易截然二分，彼此常有重疊之處。此外，由於中國史受到朝代更替底下後朝修前朝史之影響，向來有斷代史的分期，故不免如邱文所認為之以臺灣各政權為分期，可能陷入過去史學教育的巢臼。不過當今新興的臺灣史論述，並非由國家執政當局所形塑的，而是從20世紀的70年代、80年代，由民間、學術界所啟動的，到了90年代才獲得社會力及政治力一定程度的支持，並因而產生在此所談的臺灣法律史論

24 王泰升，土地、人民、法律與歷史，收於：王泰升、薛化元、黃世杰編，追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究，3版，頁269-272（2016年）（初版為2006年）。如果我在文章中一再重述這些內容，恐怕讀者也會不耐煩吧。

述，故其所抱持的是來自社會或學術，而非純然國家的觀點。只不過如下一段所述，剛好政權或國家的替換所帶來的「人的流動」及「法的流動」，是造成法律規範及法律文化變遷最關鍵的因素，故在政治史之外，同時以之為法律史的分期依據。

在臺灣，政權或國家的變動決定了實證法秩序的內涵，以及制法與執法階級的文化屬性，再以多元鑲嵌的方式形成運作中的法律。對臺灣而言，原本居住著原住民族，施行原住民族法律。荷蘭及西班牙政權帶來歐洲人的移居，其引進前近代西歐法律，並以其基督教法律文明觀施政，一部分原住民族及被招募的漢人移民因而在法律生活中添加了西歐法律元素。鄭家政權帶來的漢人，引進漢人傳統的法政體制，但不乏荷蘭時代的制度被延續。清朝帶來大量漢人的移居，引進中華帝國的統治架構及漢人法律傳統，同化了平埔族原住民族，使臺灣的多數人口過著傳統漢族的法律生活，僅少數人維持原住民族法律生活方式。日本帝國帶來日本人的移居，其引進已繼受近代歐陸法系的日本法制，由具有明治法律經驗的日本統治階層掌控在臺的國家實證法，但臺灣人的法律生活兼有現代及傳統的元素，高山族原住民族則保有較多固有的法律生活方式。二次大戰後中華民國的接收，帶來外省族群的移居，其引進同樣繼受近代歐陸法系的中華民國法制，由具有國民時代中國經驗的外省族群菁英掌控在臺的國家實證法。1950年代起與美國在政治及經濟上的結盟，移植若干屬英美法系的美國法上制度，且引進戰後德、日等自由民主憲政國家的法學理論或法制。1970年代起則開始逐漸轉變為，由臺灣人民決定自己的法律生活方式。換言之，每次政權或國家的變動，都對人民法律生活造成很大的衝擊，足以作為法律史的分期基準。甚至從該項變動每每造成人民的財富重分配²⁵，故也

25 專研臺灣經濟史的吳聰敏，曾指出臺灣在1662、1684、1895、1945年經歷4次政權轉替，都造成人口大量遷徙，而有移出人口的財富由誰承接的問題，造成整個臺灣社會的財富重分配。參見吳聰敏，改朝換代與財富移轉，2018年度研

是臺灣經濟史的重要分期方式。

顏文另一個質疑是，在上述某些時期，臺灣並非全由一個政權統治，例如「清治的大部分時期似宜界定為『清原分治』」。這項觀察如前已述，有其一定的道理。不過若把當時都未統治今之臺灣全域的荷蘭或西班牙政權、鄭家政權、清朝之出現在今之臺灣這塊土地上，當作該時期的特徵，則如上一段所述，該特徵已導致法律生活產生新的變化，則這樣的分期應說得過去吧。

不過，在政權或國家更替後，人民法律生活真的「產生新的變化」嗎？顏文指出「有許多法學理論處理的議題，可以由跨政權的角度來思考。……因為有許多問題，是社會本來就會持續出現的問題，與政權無關。」我也贊同「跨政權」的觀察是一個可能的選項。在另文曾表示：「在某些事項上，實有必要跨越政治上的朝代來做整體觀察。就臺灣法律史而言，不知清治末，無從了解日治初，不知日治末，無從了解國治初。……對許多在社會生活秩序發揮甚於國家法的規範機制（例如商業行為、分家），國家政權的轉替時點並不一定具有實質上轉折性的變化」²⁶。

顏文再提醒「法律史涉及的一個重要層面是，用新的觀念架構看事情，而不僅是用新的法律管事情」。而我在另文提出「2. 法律文明的類型」分期，即已顧及這一點。並以清治晚期臺灣向西方開港通商後，臺灣的漢人就透過與英商等的往來，吸收近代西方的商法觀念為例，說明繼受西方法非自1895年日本統治後才開始，除非是限定於國家法律的繼受，而1945年到來的中華民國法也不過是接踵為之而已²⁷。另外還有一種情形是，雖然新政權或國家改用新

討會：台灣戰後初期的財富重分配，台灣制度與經濟史學會、國立臺灣大學經濟學系、國立臺灣大學法律學院法律與社會研究中心合辦（2018年12月15日）。

²⁶ 王泰升（註24），頁271。

²⁷ 王泰升（註24），頁271-272。

的近代西方/現代的法律概念或條文，但是所實現的還是舊的、原存在於清治時期的文化價值觀。例如，清治時期廳縣地方官對戶婚田土錢債為裁斷的紛爭解決方式，在日治時期被轉譯為現代型國家及法制下，地方行政機關首長透過調停官所為的民事調解²⁸。但話說回來，正因先用政權區分了清治、日治，並了解各自相異的法律體制，才能觀察到這種法律文化觀念的跨政權延續。

陳文以其作者專精的德國法制史為例證，認為可「從選擇的研究出題出發，針對特定主題的重要時間點轉折」，進行臺灣法律史的分期。我亦贊同此說，其接近我在另文所提出之「3. 依法律規範的內容或特性」。例如，臺灣在現代法底下處於「非常法制」，須從日治時期的1937年或1938年戰時法令開始觀察起，且不為1945年的國家變更所中斷，而接續中華民國法秩序上，1945年為軍事接收、1947年國家總動員法繼續生效、1948年進入動員戡亂時期、1949年發布臺灣省戒嚴令，直到1991年的終止動員戡亂宣告²⁹。至此，對邱文所問：「有沒有其他更有趣味或更有啟發性的分期法？」應可肯定地說，當然有，就看研究者的巧思了。

貳、邱文部分

至為感謝邱文坦誠地對拙文進行批判，這樣才有機會澄清某些對臺灣法律史研究、或者對我個人容易產生的誤解。對邱文所為的評論，在前揭綜合回應中較少觸及，故在此先於陳文及顏文而為回應。

28 王泰升，去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型，修訂版，頁19-24（2017年）。

29 王泰升（註24），頁272。

邱文指出，「以中國為中心」在中國史研究是有正向意涵的方法論提醒，但在我的論述裡卻有負面意義。事實上如拙文註20所示，我曾以清朝地方衙門審案機制為討論對象，亦即作為中心，在中研院史語所期刊發表屬於傳統中國法/中國法律史的論文，當中就以「從傳統中國理解傳統中國」為標題之一³⁰，故基本上是贊同邱文所理解的「以中國為中心」來研究中國史，不致於視為負面。不過，當學界出現臺灣法律史這樣的新成員，總會引起作為既有成員的中國法制史/法律史側目。是以拙文註17所註解的正文，表示欲「尋求與當時在臺灣文教界占絕對優勢的中國國族主義思維對話及交流」。並以註19之例說明「以臺灣為主體而觀察法律史，不可能『去中國化』」，但「以何者為中心，係依研究者所預設的認識目的而定，臺灣的歷史研究者以臺灣為認識目的，是再自然不過的事」。為避免被誤會為排斥中國史，還在註20表示「臺灣的歷史研究者，亦可將中國當作認識目的」，從而研究中國史。承襲前述「共通的部分」所言，以臺灣為中心的臺灣史可能談及中國，例如拙文註18謂：「從臺灣法律史出發的『民國時代中國』……對臺灣法律史的重要性有如『戰前日本』」。以中國為中心的中國史也可能談及臺灣，例如前揭論中國清朝地方衙門審案機制之文，係以發生在臺灣的《淡新檔案》為史料依據。不過，拙文最終是以【圖3 多源而多元的台灣法】為基礎，主張「以臺灣為主體的法律史，須從世界史的眼光看臺灣的法律發展，……方能認識臺灣的全貌。讓臺灣法律史可走出去，……，也讓世界其他地域法律史可走進來」。需關照的是「世界」，而不僅止於「中國」。

邱文數次提及拙文有「第三要」，亦即「要去掉『以中國為中心的法律史思維』，臺灣法律史研究才可以更完整地學科化」，但此是否為過度引伸？邱文為推論出存在這樣的「第三要」，所引用的

30 王泰升、曾文亮、吳俊瑩，論清朝地方衙門審案機制的運作：以《淡新檔案》為中心，中央研究院歷史語言研究所集刊，86本2分，頁459（2015年）。

原文，出自拙文「結語」第二段。不過，該原文應從其引用部分的更前端看起，亦即：

在臺灣自身的法律上，迄今臺灣還不是一個國家。……目前臺灣政府在中國強權的武力要脅下，不願明白調整憲法上的國族想像，故長期宰制臺灣法律社群之以中國為中心的法律史思維……，得以延續，「臺灣」仍舊只有附帶被提及的份……，臺灣法律史因而難以被學科化。

這是針對「目前國家憲法規定」與「學科化有困難」兩者之關係，所為經驗事實上的因果詮釋³¹。按拙文在談最早的1995年所提「台灣及其東亞鄰國法律發展圖」時，曾說：「這是從實際生活經驗，而非中華民國法秩序出發」。這項刻意不依從中華民國法秩序的觀點，正是韓忠謨所稱「當社會生活情況與經濟條件有新的改進時，……在新的時代中居於指導地位，恰與原有法之理念（法內在正義）彼此對立」的「法超越的正義」，「雖然同樣代表正義，可是它的精神超越於實定法之上」³²。臺灣社會1990年代以後逐漸形成的「以臺灣為中心」的觀點，超越了只將臺灣限定為一個「地區」的現行法秩序，故不為僅僅關注於現行法的法學者所在意。且臺灣法學界向來偏好把歐美日本等外國的法學理論或法制，直接當作「法超越的正義」，以批判本國法，但這些外國的法理論或法制幾乎

31 我也曾對目前中華民國憲法仍宣稱領土及於中國大陸的「果」，提出引文所述之現今中國以武力威脅之外的另一個「因」，亦即1949年年底來臺之由蔣中正所領導的「遷占者集團」，當年所帶入之關於國家及歷史的想像，於今之臺灣猶具一定影響力。王泰升（註14），頁78。

32 韓忠謨，法學緒論，6版，頁129-130（1977年）。威權時代任教於臺大法律系的韓忠謨，在該書同一頁繼續說：「實定法對於『法超越的正義』往往實施干涉壓制，甚至臨之以嚴刑峻罰，產生兩種正義對立的悲劇，我們一般所見『政治的確信犯』……無非就是這種對立的現象。」當今臺灣何其幸，已無前述兩種正義對立的悲劇，但仍需培養承認法超越正義的胸襟。因此臺灣國族認同或中國國族認同，應均為以臺灣作為國家的自由民主憲政秩序所容許，但民主國家有其自我防衛機制，故不容超越言論層次而著手以行動，將臺灣改變為僅承認中國國族認同的中華人民共和國的一部分。

不會強調應以臺灣為中心。從而，法學界根本沒太多人有機會知悉臺灣法律史，也就不可能認真思考其應否學科化的問題。

為延續這個論述，拙文在下一段還提及原為英國殖民地的美國，因有一部視美國為國家而非殖民地的憲法，故美國法律史較易成為研究及教學上的一個領域，亦即「學科化」。但就像具有研究傳統的英國法律史、歐洲法律史等依然存在於美國學界，臺灣法律史之成為學科，並不妨礙中國法律史之續存，當然也不以去除中國法律史為必要。然而臺灣能否出現這樣的一部憲法，乃是政治問題。因此拙文表示：「在政治尚未改變之前，學術上應堅持的是，不斷地深化知識本身，也就是臺灣法律史的內涵。」換言之，臺灣法律史之難以學科化有其政治因素。就此邱文認為我「強調的是某種學術與政治之間的有機互動關係」，確實沒錯；但有所誤會的是，縱令如此，身為學術工作者的我，仍認為學術內涵的強化，才是邁向學科化所應努力的方向。

邱文指摘拙文在談如何學科化時，「似乎還想將個人的國家認同或政治理想，進一步推昇為臺灣法律史的學術工作『旨趣』」，則是再衍生的想像。容我直白地回應，我不會陷入常見之以歷史作為動員國族意識的工具³³。歷史是講過去，而過去是否為國家，與未來應否為國家，根本是兩件事；過去決定了現在，但不能決定未來，因為現在可以改變。若追問的是臺灣法律史學術工作的「旨趣」，則拙文已表示法律史研究僅得出法經驗事實，但期待能據以提供有關實踐評價上的論述，亦即將臺灣法律社會史的知識，運用於屬於實踐評價的法制訂及法適用，並以「參、二、法律史在法制

33 我在1990年代後期撰寫的〈台灣日治時期憲法史初探〉，並未以1920年代臺灣青年已出現高層次的自由民主憲政思想，而鼓吹「作為臺灣人的光榮」，反倒指出歷史的真實是，其僅係1920年代在臺灣社會中占少數的知識菁英的想法。參見王泰升，台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，頁246-249（2006年）（初版為1997年）。

訂與法適用上的運用」，及數頁的篇幅闡釋其作法。或許邱文與不少之前我曾聽聞的批判一樣，認為我所為的學術工作都帶有政治目的，故以下願就此詳述己見。

我曾指出，岡松博士透過《臺灣私法》這部經典之作，所創造之以歐陸法律概念轉譯漢人習慣的知識一直流傳至今，但其期盼藉由總督府當局的政治力所推動的舊慣立法，卻因政治風向轉變而一切白費，須待1990年代政治民主化之後，岡松式的習慣立法才在臺灣獲得實現。藉此說明學者的本務在於創造學術知識及見解，而不是其學說被立法、行政等政治部門或被法院等法律部門所採納；所以學者之見，若不能為其所處的當代社會或國家所接受也無妨³⁴。若邱文所言：「我們學者真能代表全體國民來對國族想像進行『調整』嗎？」是對我的質問，則我的回答是：身為學術工作者，的確在獨立思辨後擬向全體國民提供一個可以調整的選項，但從未自以為可代表全體國民，或經由政治活動尋求這項代表。

邱文認為我「在提倡法制史研究學科化的同時，……呼籲要用臺灣法律史研究成果來『調整憲法上的國族想像』」，似乎過於簡化。正是為了實現邱文所說：「全體國民與其他學者在此議題上也都有自行判斷與選擇的自由與責任」，我才倡議前所定義之作為學科的臺灣法律史，以提供更多與「憲法上的國族想像」相關之具有相互批判可能性、可為學術辯詰的法經驗事實，俾便法學者將其運用至不在於證明是否存在而在於申述妥當與否、屬於實踐評價的法制訂及法適用，包括「應否」調整憲法上的國族想像，非法學者則可據以思考及表達關於國族想像的各種看法³⁵。透過學科化而能充

34 參見王泰升，具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，頁206-207（2010年）。

35 討論到「憲法上的國族想像」的《臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」》，在「緒言」亦曾做過類似的說明，顯然這一點頗易受誤解。我表示：「筆者在學術上以臺灣主體意識的觀點進行論述，自有實踐上的意義。亦即，倘若我們現在採取了臺灣主體意識，即可看到如本書所詮釋的法律現代

分揭示相關的法經驗事實，方有真正的「自行判斷與選擇的自由」。

事實上，我的「國家認同或政治理想」光明正大，不必遮遮掩掩。在最早的1992年以英文所完成的博士論文、1999年另外出華文版的《台灣日治時期的法律改革》，於「緒論」即指出「為了有效地進行學術討論，論者應該先表明個人主觀的價值選擇，一方面暴露其在史實認識上可能有的侷限，另一方面亦揭示其作成評價的根據。」並在自行揭示政治立場為「將台灣（台澎金馬）當成一個政治共同體」的同時，直率地對不同國族認同者說：「將台灣當成『中國』這個政治共同體的一部分，何嘗不也是另一種主觀的政治立場。」³⁶可見我對於自詡中立客觀、但實為隱藏特定價值觀的歷史敘事，自始就抱持著警戒之心。因此順便回應陳文的提問，我認為研究者表明個人的政治立場是件好事，故當本世紀初推出臺灣法律史教科書時，第一章開宗明義就表示採取「人民史觀」與「臺灣史觀」，且「我們」的歷史應包含所有在臺灣不同族群的過往³⁷。而在應然層面，我曾以專文主張，應在臺灣建立一個包容不同國族認同的憲政秩序的國家，對臺灣的國家認同，即是對這個憲政秩序的認同，不必糾結於國家的名稱³⁸。

化歷程，進而據以省思：同樣在臺灣主體意識下，未來應如何制定或解釋適用法律。這就像進行婦女史的研究動機，經常是為了在實踐的面向追求性別正義，原住民族史的研究也經常有追求族群正義的實踐上目的。至於當今臺灣生活共同體的所有成員，在理念上是否採納臺灣主體意識，係各個人主觀上的抉擇，應予以尊重，但仍需不斷的相互溝通與說服（註：粗楷體為撰寫此回應之文時才增添）。」王泰升（註14），頁4-5、79-105。

³⁶ 王泰升，台灣日治時期的法律改革，修訂2版，頁19-20（2014年）（初版為1999年）。

³⁷ 王泰升、曾文亮、吳俊瑩（註30），頁465、468。

³⁸ 參見王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（八）（上冊），頁103（2014年）。

以一篇可能被認為具政治色彩的論文為例，具體說明之。1997年中國開始以「一國兩制」統治香港，且世人認為此舉帶有劍指臺灣之意；此時我發表一篇〈日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」〉³⁹。此文從臺灣作為一個政治共同體的立場，指出臺灣歷史上，日治時期即曾出現過類似當時中國在香港所施行的「一國兩制」。基於這項研究動機⁴⁰，先以4節論述日治時期的「新領域統治基本法的確立概況」、「台灣地域的法源種類及內容」、「台灣行政機關之組織與權限」、「台灣司法機關之組織與權限」。以上是對歷史事實的敘述，讀者可嚴格地檢視研究者有無因為臺灣主體的立場，而掩飾或增添任何法經驗事實。該文最後一節是「台、日『一國兩制』的歷史省思」，作為省思根據之價值觀，就是以臺灣為主體，故質問「既需『兩制』何必『一國』？」⁴¹此即基於學術研究，而向個人主觀所選定的臺灣人民提出建言⁴²。評論者當然可以不接受我的臺灣主體立場及價值觀，但若從我所清楚

39 參見王泰升，日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，頁153（2006年）。

40 該文如下這段話，應已揭露此研究動機：「對於今日大多數的台灣人民，在中國本位的歷史教育下，日治時期早已是一段被遺忘的歷史，日治時期台灣曾經有的『一國兩制』，更是被摒棄於歷史記憶之外，甚至當外來強權為併吞台灣而祭出『一國兩制』的亡魂時，猶不自知。」王泰升（註39），頁152。

41 參見王泰升（註39），頁99。

42 該文指出，「從台灣人民的觀點，在需要『兩制』的現實底下應否合為『一國』，必須由台灣人民基於自身整體利益的考量而為決定。雖因存在種種差異而須『兩制』，但仍不排除屬『一國』的可能性。一九二〇年代及三〇年代前半期，……希望藉由『台灣議會』的設置追求台灣殖民地自治，……仍是立基於『一國兩制』的維持上，並未要求台灣與日本各為『一國』。這是那一代台灣人，本於當時情勢的判斷所為的選擇。那麼，我們這一代台灣人，又應該做什麼樣的選擇呢？……日治時期的『一國兩制』，使台灣的立法、行政、司法皆具備相當的獨立性，已為建立一個獨立國家的法律體系奠定基礎，……且一九四九年以後，台灣事實上以中華民國為國號，單獨做為一個主權獨立的國家而存在，……在客觀條件上，已足以將台灣的『一制』提升為『一國』法律體系。……未來一代的台灣人，當然也可以基於其利益衡量，再次就『兩制』選擇是否合併為『一國』。在此所反對的是，那種以『台灣是某國神聖不可分領土』為由，全然漠視土地上人民之意願，『指腹為婚』式的合併要求。」王泰升（註39），頁155。

交代的立場或價值觀出發，有什麼論述的基礎事實不存在或推理過程不合邏輯？均可進行學術辯論。

或許因所屬科系不同，邱文作者不太了解臺灣法學教育界實況，故當其憶起在臺大歷史系唸書時並未因受「宰制」而不能研究臺灣史時，大概不知我曾在歷史界的《新史學》期刊，沈痛地表示自己在臺灣接受從學士到碩士7年的法學教育，卻對四、五十年前日治時期的法律是什麼聞所未聞⁴³。拙文亦提及，曾是歷史界關於清治臺灣被引用率第一名的戴炎輝所著《清代臺灣之鄉治》，我也是到美國留學後才知道有此書。於今與我同輩的法律界朋友，幾乎都不知道日治時期有什麼叫「六三法」的東西，這卻是現在臺灣一般國中生就懂的歷史知識。相較於邱文所說：「回到二十多年前的臺灣，一位史學初學者如何因為『以中國為中心的法律史思維』而受『宰制』故而不想研究臺灣法律史？筆者很難想像。」當年的法律系學生，是沒想過居然有臺灣法律史這樣的研究領域，其根本不成為選項；如拙文所言，戴炎輝在臺大法律系不曾以臺灣法律史為講授主題。宰制之極，即是讓人不知宰制之有。唯有理解那種「自己族群歷史被國家教育抹殺」的椎心之痛，才能理解我為何要呼籲臺灣法律史需要學科化，以在學界有一席之地，且本於已所不欲，勿施於人，在拙文的「肆、作為學科的既有內涵及未來課題」，以「一、已有各時代及各族群的法律史」的標題，提示臺灣法律史務須涵蓋福佬、客家以外的原住民族、外省族群、今之新住民的歷史經驗，乃至在定義臺灣法律史時，堅持要涵括目前與臺、澎同屬一個生活共同體的金門、馬祖人民的歷史經驗。

就邱文談及的法律史在法學教育中的定位，在此須明確地主張，在臺灣的法學教育裡，臺灣法律史是主，中國法律史是輔，就

43 參見王泰升，來回穿梭於法律與歷史之間，新史學，21卷3期，頁188-189（2010年）。

像傳統中國法、日本近代法律史、歐陸法律史、美國法律史等等都是輔。換言之，臺灣法律史與中國法律史或傳統中國法，是可區隔、而併存的學科；但在臺灣，臺灣法律史優先。按臺灣的法學教育主要是培育制訂及適用臺灣的法規範的專才，而這些法規範必須與臺灣社會/共同體的經驗事實相連結，因此以探究臺灣社會/共同體為認識目的的臺灣法律史，是學生所必需的。即令是來臺灣習法的外國學生，為了理解臺灣的法律體系，也必須具備臺灣法律史的知識，方可比較臺灣與其所屬國家之異同，以增進相互間了解與友誼。我所主張的「歷史思維法學」，特別強調法律社會史與法律規範論證的結合；對臺灣而言，當然臺灣法律史比起其他法律史，更符合這個「運用」上的需求。就像中國的法學院優先講授關係最密切的中國法律史，臺灣的法學院亦優先講授關係最密切的臺灣法律史。

不過，我完全同意邱文所言：「臺灣法律史研究與中國法律史研究其實『合則雙美』，大家努力做好自己本分研究工作，並試著彼此日後增加更多對話」；臺灣學者各依其興趣或認識目的而研究各種法律史，更是不必用問號的當然之事。我在1990年代剛開始研究臺灣法律史時，常在探究日治時期時可參閱眾多的近代日本法律史論著，卻在探究中華民國時期時，不易找到討論民國時代中國史的論著。其後民國時代中國史逐漸興盛，受益於此，於今探究戰後臺灣法律史省事多了。例如2015年為文探究臺灣司法官社群文化中的中國因素，即大量參考除了臺灣學者之外，還有今之中國學者所撰寫的清末民國中國法律史論著⁴⁴。我個人在研究臺灣法律史的過程中，也同時為中國法律史累積了一些重要的史料。例如拙文註18之中，與註60及其正文所言，記錄1949年以前中華民國法院民刑事審判過程的《最高法院遷臺舊檔》，就是我協助司法院發現、命名

44 王泰升（註8），頁42-44。該文共有42筆華文的參考文獻，其中由中華人民共和國的學者所撰寫者有11筆。

並促成各機關一起整編。且從確立編目原則，到對於修補後原始文件一張一張檢視，無不參與，最後方由中研院的臺灣史研究所檔案館對外公開。臺灣史關心所有曾居住在臺灣的人、曾發生在臺灣的事物，故當然不排斥中國史。

邱文提到有不少中國大陸研究者，對我所提出的法律史感到興趣；事實上我在中國以外的地方，常有機會與彼等為學術交流。在美國、日本等學界訪問時，或者在臺大的課堂上，經常遇到來自中國的學者或學生，而與之討論者大多為中國法律史，因為這是他們最需要、對其國家法制最有幫助的法律史知識。也經常會論及同一事項或法律領域在臺灣的發展歷程，以讓學術議題具有更開闊的視野。前揭「臺灣與中國法律發展軸線示意圖」，正是在臺北大學法律系上課時，為回答一位中國學生的問題而劃出來，以就其關心的中國法律史的議題，提示可觀察或思考的方向。此外，一些在德國、日本唸書的中國留學生，曾因指導教授的建議而來臺灣與我晤談，還有在美國或其他英語系國家攻讀博士的中國學生，因看過我的英文論著而來訪。此時所討論者大體上是其所研究的中國，尤其是清末民國時代的法律史議題。由於我的著作不能通過中國政府對輸入書籍所為的審批⁴⁵，故無緣與中國當地法律史研究者為學術交流，但此非我所願、亦非我所能改變。

感謝邱文建議我多參考法律多元論。回應之文一開始提到，1997年曾以英文在「亞洲法律體系」一書以專章撰寫臺灣的法律，該書的副標題就是「東亞的法律、社會與法律複數主義」(Law, Society and Pluralism in East Asia)。其實我受原本不相識的澳大利亞學者邀請而加入該專書的寫作，很可能是因1992年以英文探究臺灣殖民地法律的博士論文（華文版為《台灣日治時期的法律改

45 因擔任臺大出版中心主任，故見證了該中心所出版之我的論著，由於未通過中國政府的審批，不能送往在中國舉行的國際書展。

革》），已參考法律複數主義研究先驅M. B. Hooker的1975年論著⁴⁶。不過關於臺灣法律史與各種理論之間的關係，已在拙文有所說明；我個人採「以無學派為學派」的態度，但作為學科的臺灣法律史，當然任各方學者引用各種理論來發揮。拙文在介紹「從法條到法社會發展歷程及其可能的互動示意圖」時，特別表示：「該示意圖僅用以描述台灣從日治迄今所採之歐陸法系國家法規範體系，不適用於討論日治之前的傳統中國法施行經驗，以及未為台灣所採的英美法系國家法規範體系」，故無意將其視為一般性的理論，而僅是為描述特定時期臺灣而「客製化」的模型。

邱文也提及「若要更加講究臺灣法律社會史的方法論，也可再多引其他學者的重要成果。特別是像淡新檔案相關研究……」；不過，在我個人的研究歷程，已參閱過邱文所列的大多數論著。邱文中所言包恒（David C. Buxbaum）、艾馬克（Mark A. Allee）、黃宗智（Philip C.C. Huang）等英文作品，及與黃富三之文密切相關的《霧峰林家的中挫（1864-1885年）》，均為1999年《台灣日治時期的法律改革》一書的參考文獻⁴⁷。我從1994年起到2015年，一直在臺大開設學生須以《淡新檔案》為史料寫期末報告的課，亦曾指導以該檔案為主要史料來源的碩士論文、專文介紹過這份史料⁴⁸，故對於與該檔案相關的論著並不陌生。是以邱文所言滋賀秀三之文、林玉茹之文、黃宗智及林文凱的相關研究，乃至邱文未提及但亦屬重

46 See M. B. HOOKER, *LEGAL PLURALISM: AN INTRODUCTION TO COLONIAL AND NEO-COLONIAL LAWS* (1975). 參見王泰升（註36），頁433。

47 王泰升（註36），頁418、427-428、433。

48 參見陳韻如，*帝國的盡頭——淡新檔案中的姦拐故事與申冤者*，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2004年）；堯嘉寧，*官府中的紛爭解決——以淡新檔案觀察相當於今日新竹市之區域之案件*，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2005年）；王泰升、堯嘉寧、陳韻如、戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話，*法制史研究*，5期，頁255-325（2004年）。陳韻如本於撰寫該碩士論文的經驗，最近發表一篇與《淡新檔案》相關的論文，參見陳韻如，*《淡新檔案》中姦拐案件：法律傳統的重新檢視*，*臺灣史研究*，25卷4期，頁21-73（2018年）。

要的寺田浩明、鈴木秀光的作品，皆出現於2015年我與曾文亮、吳俊瑩合著論文的引用書目中⁴⁹。

邱文特別就黃靜嘉1957年完成的政大政研所碩士論文、1960年出版的《日據時期之臺灣殖民地法制與殖民統治》，提醒「前人開創之功仍足珍貴」，然恕我魯頓，猶不解其意。我在1995年回顧臺灣法律史相關研究時，就曾評介該書⁵⁰，且1990年代撰寫《台灣日治時期的法律改革》，經常參考該書，同意其所論者固然引用之，不同意但可對話者亦引述其見解，已表示對先行研究的尊重⁵¹。然黃靜嘉2002年將舊作增補後再次出版《春帆樓下晚濤急：日本對臺灣殖民統治及其影響》，似不願就如何釐清日治時期的歷史事實，與我進行學術上相互辯詰；2010年曾將此情事，揭露於歷史界的《新史學》期刊上⁵²。作為學科的臺灣法律史，如前所述，不問以

49 王泰升、曾文亮、吳俊瑩（註30），頁465-468。

50 王泰升，撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，2版，頁77（2006年）。

51 其詳，參見王泰升（註36），頁69註11、頁77註37、頁87註58、頁97註92、頁100註107、頁102註112-113、頁103註117及120、頁104註121、頁119註166、頁313註4、頁351註77、頁356註87。

52 王泰升（註43），頁195。黃靜嘉2002年新書謂：「是否得認為日本係臺灣法制之改革者（註2）？這些溢美日本殖民統治的說法，如係出於無視歷史真相，已足令人扼腕；如係蓄意曲解，藉以貶抑對父祖原鄉之認同及紐帶，尤足令人慨嘆！」。經查該「註2」係：「參閱第三章第二節第二目註6」，而該「註6」記載著：「Tay-sheng Wang……作者因而稱日本為臺灣法制之稱職的改革者（competent reformer），見其論文摘要。」在此所謂「論文摘要」，係1992年我以英文所寫博士論文的一份只兩頁的英文摘要，但2002年時，我的博士論文不論華文版（即《台灣日治時期的法律改革》）或英文版都已問世，黃靜嘉新書卻僅引用該論文摘要上的一句話：「日本係臺灣法制之改革者」，忽略這句話緊接著是：「但臺灣人為獲得這般由日本人主導的法律改革的副產品，付出極大代價」（原文：“Indeed the Japanese regime was a competent reformer in Taiwan’s legal modernization. But the Taiwanese paid tremendous costs for the by-product of such Japanese-led legal reform.”，臺大圖書館有收藏這本博士論文，網站上對該論文的「描述」，即是前述這份論文摘要）。黃靜嘉對於為什麼「這些」乃是「溢美」之詞的理由，只概括地說：「細譯本書各章之相關論述，即足提供……反證」，根本不言明到底針對何項事實、或何種說法，根據什麼史料或理由而有什麼不同意見，故無從與之進行學術對話，其卻逕對學術研究工作者給予

什麼意識型態作為詮釋歷史的依據，故黃靜嘉新書亦歸入臺灣法律史作品，但也因此須受學術標準的檢驗。

參、陳文部分

陳文首先提及「法律史」與「法制史」的用語問題。在戰後臺灣，沿襲實受日本影響之民國時代中國法學界的傳統，一直採用「法制史」的稱呼，且向來是以「法律制度」，亦即法律規範本身，作為主要的討論對象。因此喜歡談現行中華民國法規範的制訂過程，包括當時在清末民國的中國曾有哪些法規範版本，有時會交代一下其與日、德、法等歐陸法系國家的法規範有什麼關係，並因而研究羅馬法。就「中國法制史」，也是談中國史上曾有的唐律、大清律例等典章制度本身。但我的研究興趣是人民的法律生活經驗，即「從法條到法社會發展歷程及其可能的互動示意圖」當中的社會上法律生活，故向來「法制史」所指稱的法律規範本身，相當於前揭示意圖中的法律條文、法學理論、個案適用法律等，僅是研究對象的一部分。為凸顯所採取的研究取徑已有別，乃改以「法律史」為名稱，標示研究對象為所有的法律現象，而不止是法律制度。按在臺灣有稱「法律學院」、有稱「法學院」者，「法律」與「法」並不像日本那樣嚴格區分為一個是指立法機關制定的規範、一個是指各國家權力部門，乃至超越國家機關所為實證法（positive law）的所有規範，故稱「法史」亦無不可。如之前在《追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究》所述，擬以新的用語，「作為一種學科發展上的行動策略，除了揭示對於研究對象的擴大外，也希望藉藉此對社會學、政治學、經濟學、人類學、文學等等研究取徑，保

「無視歷史真相」、「蓄意曲解」這般嚴厲的指責。參見黃靜嘉（註22），頁45、458-459、462。

持開放的姿態，以催生豐富多元的『法律—歷史』研究圖像。⁵³」對此，陳文表示：「本文作者使用『法制史』一詞主要認為『法制』一詞包含『法』與『制度』範圍比較廣泛。」其實不是很確定其所指涉的討論對象，與我是否有異或異同何在，不過這個名稱問題，就像研究取徑一樣，可由研究者自由選擇。

在談完研究對象與分期後，陳文對於拙文就臺灣法律史研究上的方法論表示「屬於『臺灣研究』的一支」，認為「『臺灣研究』範圍過於廣泛，因此僅針對臺灣法制史作為臺灣史研究一支進行討論。」惟承上所述，當我將臺灣法律史的觀察及論述對象定義為「與法律相關的」法律現象，甚至將其意涵具體明確化到前揭「從法條到法社會發展歷程及其可能的互動示意圖」所示的法律條文、法學理論、個案適用法律、社會上法律生活等的「底層因素」時，所需要的知識範疇，已非「臺灣研究」不可。例如就臺灣法律條文之底層因素，欲追問「政策考量及政經社文等條件」，當然須獲得以臺灣共同體/地域社會的政治、經濟、社會、歷史及文化等為主要觀察及論述對象的研究，亦即「臺灣研究」提供的知識，方能探究其與法律條文之間的關係。如此所觀察或論述出的法條生成因素，即臺灣法律史的內涵，不也是以臺灣為主要觀察及論述對象的「臺灣研究」嗎？

再者，陳文似乎認為臺灣史研究當中，「多數跟法律制度相關，不當然強調法學觀點」，以致其非臺灣法制史。不過我是以主要的觀察或論述的對象，是否係與法律相關的經驗事實，來決定屬於臺灣法律史與否。不論是陳文提及之林文凱從歷史社會學觀點探究清治、日治臺灣社會的論著，或者探究日治時期笞刑對竊盜犯罪之嚇阻作用的經濟學系碩士論文⁵⁴，均屬於臺灣法律史的作品。其

53 王泰升（註24），頁262-263。

54 參見李維倫，日治時期台灣笞刑之研究：以竊盜罪為例，國立臺灣大學經濟學

實若將「法學」的概念放大，前述見解上的差異好像也不大。例如探究法律制度在社會生活中所扮演的角色或功能、法律制度與社會之間的相互影響或形塑、經濟因素之於法律制度的形成，即可分別視為出於法現實論（Legal Realism）、法與社會之研究（Law and Society）、法的經濟分析（Economic Analysis of Law）觀點，而被納入「法學」研究的範疇。也因此，拙文註37的正文表示「法律史學是一門法經驗科學」，拙文註45所註解的正文進而謂「上述法經驗科學的研究成果可稱『法律社會史』，其與『法律社會學』並無本質上差異」。目前我在臺大法律學院所開課程，名稱為「台灣法律社會史專題研究」。

陳文亦肯定比較法史研究的重要性，並認為需要學者「針對自身社會法律制度的發展進行比較分析與研究。在每個議題上，都需要更多研究者，從不同角度，針對相同主題進行研究。如此才能對於法制的運作與社會與法律的互動有更深刻的理解」。對此拙文也完全同意，且在前述對臺灣法律史相當寬廣的定義下，陳文註56及其正文所提及的吳豪人以及日本學者所做的研究，都是作為學科的臺灣法律史所引頸期盼者。詳言之，吳豪人1999年即提出「台灣法史」，並定義為：「以民族認同為基礎，運用法史學方法論，並佐以其他學科的研究成果，將台灣過去的法制度、法事實、法現象、法感以及法思想視為研究對象的學問。⁵⁵」且於2017年出版其認為「探討他者—日本殖民（法學）者的本質，盡量不及於台灣的近代法律人」的《殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像》⁵⁶。我在2010年出版的臺灣法律史論著，亦本於吳豪人該書所討論的岡

研究所碩士論文（2007年）。

55 吳豪人認為這項定義與王泰升所採用者應該是並行不悖，且在以日文書寫的博士論文，特別將「台灣法史」視為專有名詞，使用臺灣慣用的漢字「台灣」，而非日文中的漢字「台灣」。吳豪人，「台灣法史」の可能性：法社会史的・法思想史的試論，京都大学大学院法学研究科博士論文，頁3-4（2000年）。

56 吳豪人，殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像，頁xliii（2017年）。

松參太郎涉及「從法條到法社會發展歷程及其可能的互動示意圖」中的法律條文、法學理論，姉齒松平則涉及該示意圖中的個案適用法律，而就影響日治臺灣法律的這兩位堪稱「他者」的日本人，分別以專章論之⁵⁷。後藤武秀為了向日本人介紹臺灣法律史而著書，雖出於日本人的興趣及眼光，但其作品當然有助於了解臺灣法律史，況且其係少數已使用《日治法院檔案》的研究者⁵⁸。淺古弘以其日本近代法史的高深造詣，整編日治時期臺中地方法院刑事判決，並為文介紹⁵⁹，其為臺灣法律史作品，當之無愧。尤其是鈴木賢採取與臺灣人民同樣的視角，以「當今臺灣的法律本土化」、「外來法支配的結束」等等詮釋臺灣法律史的作品⁶⁰，更是具高度學術性的論著。西英昭對日治時期舊慣調查事業出版的《臺灣私法》所為精湛的研究⁶¹，也應是臺灣法律史這個學科的重要參考書籍。

肆、顏文部分

如前所述，法律史論述應協助人們了解周遭的生活環境，顏文對此做了很好的示範。顏厥安以臺大法律系法理學教師的身分，關心在臺大法律系前身的臺北帝大文政學部政學科擔任法律哲學講座

57 參見吳豪人（註56），頁9-74、169-180；王泰升（註34），頁167-242。

58 後藤武秀本於其所撰寫的數篇學術論文，而寫成較通俗之介紹臺灣法律史的書籍，該書分成三部分：日本統治下的臺灣法、第二次大戰後臺灣法、臺灣人的法觀念。若讀者欲知後藤武秀如何運用《日治法院檔案》做研究，最好閱讀其單篇的論文。參見後藤武秀，台灣法の歴史と思想，頁48-53（2009年）；後藤武秀，台灣領有初期における民訴不受理政策——明治三二年律令第一號の制定と判決原本から見た運用狀況——，小野幸二、野口明宏、笠原俊宏編，市民法と企業法の現在と展望，頁245-268（2005年）。

59 參見淺古弘著，堯嘉寧譯，歷史分析與法：日治時期的台灣法院紀錄史料，收於：王泰升編，跨界的日治法院檔案研究，頁329-346（2009年）。

60 相關的論文4篇，參見蔡秀卿、王泰升編，台灣法入門，頁230（2016年）。

61 參見西英昭，『臺灣私法』の成立過程：テキストの層位学的分析を中心に（2009年）。

的杉山茂顯、中井淳，以及曾來臺北帝大短期講學之恒藤恭等人的其人其事，但亦對歷史敘事的「真實」，提出哲學層次的思考⁶²。拙文所謂「以無學派為學派」，確實如顏文所云，已意識到史料本身之外的理論/學說之存在，但不拘泥於特定一格。我並不喜歡大肆張揚或歌頌顏文所稱的「歷史人物」，就算寫到這些人，亦從其係歷史大氛圍底下一員的基本立場來觀察，因此贊同顏文之從其所稱「歷史中的人物」，推論出當時當地的大氛圍⁶³。讀到顏文所說，身為帝大講座教授的中井淳，「是否也深深覺得『帝國之眼』的注視是如此地難以逃避」，聯想到之前我寫過，日治時期身為醫生的臺灣人菁英賴和，在小說裡述說「他覺得他身邊不時有法律的眼睛在注視著他⁶⁴」。顏文從戰後臺灣法學界，對於日治時期曾來臺講學的恒藤恭及其學說漠不關心，而敏銳地指出可探討「臺灣現代法學發展的學說/學理繼承之軌跡圖像」。剛好最近我的一項研究計畫⁶⁵，正擬說明當今臺灣的法學基本概念來自一條歷史軌跡，亦即明治日本的「法學通論」著述，被清末民國中國翻譯或編寫成「法學通論」教科書，再移入戰後臺灣而成為「法學緒論」這個科目的主要內容。

62 對於政府檔案所表述者的真實性，我的基本態度是：「究竟案件發生時的真實是什麼？案發當時的人們都未能有十足把握，遑論處於今日的研究者，……。不過，檔案中存有可以確定的真實，那就是：這個人，在這時候，講這樣的話，或官員採取這樣的作為。有鑒於發言者為爭取別人相信其說詞，通常會盡量配合當時一般人們的觀念，故或許可從文書的文本內容來詮釋：正因為當時一般人存在著某種觀念，所以某種說詞經常出現。」王泰升（註43），頁228。

63 例如，我在敘述台北律師公會的歷史時，即不願凸顯特定的個人，而擬描繪出一般會員們的事蹟，故表示：「在公會成員的分析上，盡量透過統計的方式來呈現，而在介紹公會的實際活動時，則以整個公會為對象。其主要目的即在於呈現公會整體的歷史，而避免突出個別人物。這樣的處理方式，雖然會讓絕大多數的會員名字無法出現在會史上，但事實上，每個會員也都可以從這本公會史中看到他自己的存在。」王泰升、曾文亮，二十世紀台北律師公會會史，王序（2005年）。

64 王泰升（註36），頁286。

65 科技部專題研究計畫：「建構以台灣為主體的法學」，計畫編號：MOST 105-2410-H-002-164-MY3。

有留學德國經驗的顏厥安，以其對德文的熟悉，在顏文敘述了許多有關德國「殖民」臺灣的有趣故事，充分實踐「大家一起來寫歷史」的理念。在此想分享另一個與荷蘭人殖民臺灣，且可能與日耳曼法有關的「賸」的故事。我曾在日常生活中，聽過有人以福佬話講「賸耕」、或「賸」一個攤位等等，且獲悉臺灣客家人亦以跟福佬話相近、但不同的發音，表達「賸」的意思，甚至現行《地籍清理條例》就有待清理的土地權利，在第27條第1項第2款載有「賸耕權」。然而一般的華文辭典並無此字，在電腦上打字時只能用「插入」功能，至「中日韓統一的表意文字」找到此字。何以如此？清治臺灣的《諸羅縣志》云：「賸，俗音僕，謂散收眾社〔按：指番社〕之銀物，而包納其餉也」⁶⁶，這是17世紀荷蘭人在臺殖民統治時，依據其融合羅馬法與荷蘭傳統日耳曼習慣法若干法律觀念而成的「羅馬－荷蘭法」(Roman-Dutch Law)⁶⁷，所帶入的「pacht」制度；在譯為華文的《熱蘭遮城日誌》中，可看到許多關於賸的記載⁶⁸。經鄭治及清治200多年後，臺灣的土地上仍存在各種與賸有關的法律關係，日治時期日本統治當局先以現代歐陸法系概念將之轉譯為「賸耕權」等等，從1923年1月1日起，其再被轉化為繼受現代歐陸法系的日本民法土地上權、永佃權與租賃權。1945年10月25日起，同樣繼受現代歐陸法系的中華民國民法施行於臺灣，其權利類型依然是地上權、永佃權與租賃權，故賸耕權乃是被清理的對象⁶⁹。我曾與一位德國法律史專家聊到「pacht」，他對該制度內涵的說明，竟然跟荷治臺灣的「賸社」、「賸港」的規範意涵

66 盛清沂，明鄭的內治，收於：黃富三、曹永和編，臺灣史論叢（一），頁147（1980年）。

67 關於「羅馬－荷蘭法」，參見楊崇森，遨遊美國法——美國法之源流與民刑法之運作，頁3（2014年）。

68 可在中央研究院臺灣史研究所「臺灣日記資料庫」內「熱蘭遮城日誌」，用「賸」為檢索。臺灣日記資料庫，<http://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/index.php?search=%E8%B4%8C&button=&title=%E7%89%B9%E6%AE%8A%3A%E6%90%9C%E7%B4%A2&ithfilter=fullref>（最後瀏覽日：2019年1月13日）。

69 參見王泰升，台灣法律史概論，5版（註7），頁83、295、297-298。

一模一樣，故雖仍有待進一步查證，賸很有可能是日耳曼習慣法之一。

賸的制度，使得從世界史的眼光觀察羅馬－荷蘭法的發展時，不能忽略臺灣。有學者表示，荷蘭在17、18世紀所適用的羅馬－荷蘭法，傳入當時荷蘭人在南非、斯里蘭卡的殖民地；但在19世紀初，1809年荷蘭已採用依據羅馬法的法國拿破崙民法，羅馬－荷蘭法卻仍留存於後來不受荷蘭統治的南非、斯里蘭卡⁷⁰。賸的故事告訴我們，羅馬－荷蘭法在17世紀也被帶到東亞的一個海島——臺灣。恰似在南非、斯里蘭卡，在臺灣某些羅馬－荷蘭法的制度，例如賸，並沒有隨著荷蘭殖民統治結束而消失。羅馬－荷蘭法在荷蘭，於19世紀初被法國的拿破崙民法取代，在臺灣的羅馬－荷蘭法遺緒，於20世紀20年代亦被繼受法國拿破崙民法的日本民法所取代。不過在臺灣的漢人社會，賸卻像「老兵不死、只是逐漸凋零」般留存於戰後，有待與1900年德國民法典關係較密切的中華民國民法的「清理」。

顏文認為我以「多源且多元」來說明臺灣法的主要特色，但很多國家或地區也有同樣的特色。按我的原文是「多源而多元」，但顏文及陳文均將「而」理解為「且」，可見該用語因過於簡潔而易被誤會。我自己也意識到這點，故2010年出版的書，在第二章的章名載明「因多源而多元與外來法的在地化」，並在解說時，交代當今某個現象是來自歷史上哪一個源頭，詮釋其因果關連性⁷¹。是以拙文所寫的是：「當下的台灣法社會，除固有的原住民族法律文明外，因外來的中國法在地化而有中國元素，外來的日本法而有日本元素，外來的西方法而有西方元素，整個構成『外來法的在地化』」。亦即因歷史上存在多個源頭，以致當今臺灣社會是多元。誠

70 參見楊崇森（註67），頁3-4。

71 參見王泰升（註34），頁39-62。

如顏文乃至陳文所言，「因多源而多元」的現象在世界史上屢見不鮮，但以這句話當作該圖示的標題，是為了凸顯圖示中臺灣的4個歷史上的源頭：原住民法、中國法、日本法、西方法，這個組合在世界上應該是獨特的。

提出該圖示的目的是，以「多源」來理解「多元」。試問，臺灣在此之前的法律史論述，會談到原住民法嗎？會談到近代日本法也是極少數吧，故基本上是定於一尊，這個「一」就是漢族、中國、中華民國。我衷心期待的是，在認識到歷史上的多源頭後，能夠因理解而接納當今臺灣社會的多元性，例如有人相信源自近代西方法的「程序正義」，有人相信源自傳統中國法的「包青天」，俾能在多元的社會中循民主機制確立共同的方向。

須了解「我們」有不一樣的過去，才能相互理解與包容，追求共同的未來。例如面對臺灣的國族認同爭議，須知臺灣歷史上人群流動的「多源」現象。以撰文時的2019年為準，常聽到的所謂「臺海兩岸分離70年」，只有對外省族群才是如此。作為臺灣法律史教科書的《台灣法律史概論》，談到1945年的政治變局所引發的人口流動，曾指出當時「占台灣絕大多數人口的是，業經日本統治50年，突然無選擇地成為中國國民的本省人；占極少數的是未有台灣的日治時期經驗，已受中國國族主義洗禮的外省人。⁷²」因此對於本省人中的福佬、客家兩族群，須加上日治50年，故臺海兩岸迄今已分離120年了。但是，本省人中的高山族原住民（不含平埔族原住民）不曾受中國清朝政府統治，只在1945-1949年受到軍事接管臺灣的中國國民政府（1948年5月20日起「國民政府」已不存在，其職權由行憲後中華民國政府承接）統治，故除了這4年，與臺海對岸都是處於分離狀態，在1945年之前根本無從接觸中國國族主義；且日治50年間因其與福佬、客家、平埔族原住民適用不同的法

72 王泰升，台灣法律史概論，5版（註7），頁114。

律，基本上處於隔離狀態，故亦欠缺臺灣共同體認同⁷³。不過1949年年底由遷占者集團，亦即蔣中正領導之屬外省族群的少數國民黨政治菁英，在臺灣建立若林正丈從政治學觀點所稱「遷占者國家」的一個事實上國家，起初為了能重返中國執政，後來為了鞏固在臺的寡頭壟斷式專制統治，不斷在臺灣宣揚中國國族主義⁷⁴。雖1949年迄今的70年，不問族群別的臺灣人民，實際上與中國（中華人民共和國）及其人民欠缺共同生活經驗，但某些世代、某一些人長期在獨尊一元的國家歷史教育灌輸，以及現實的政治或經濟利益的影響下，仍抱持中國國族認同，但此已經跟原來的族群背景沒有必然關係了。唯有認識到這些複雜的歷史，臺灣人民才可理性、包容地面對「我們」國家的國族認同問題。我個人的主張，即是在回應邱文時所提的，應建立一個具有包容不同國族認同之憲政秩序的國家，並認同這個國家。

顏文提出相當具啟發性的思考方向，認為臺灣的獨特性在於「全球唯一以漢語/漢文完整繼受日耳曼法的獨特民主政體」，且「有可能發展為全球唯一以漢文，深入繼受部分普通法/美國法的獨特民主政體」。從國際上漢學研究的角度，臺灣政治共同體係以漢族/華人為主（還有原住民），不但以西方法中的歐陸法系為本兼採部分英美法系制度，且是民主政體，與專制的中國形成明顯對比，亦有別於同以華人為主但採取英美法系、民主政體與否較有爭議的新加坡，從而是「全球唯一」。但若從法文化出發，視東亞的中國、臺灣、日本、韓國等構成以儒家思想為核心的「漢字文化圈」，則前述臺灣擁有之繼受西方法模式（歐陸為本、兼採英美）及實踐民主政治的特色，同在東亞漢字文化圈內的日本和韓國皆有之，臺灣即不能謂為「唯一」。當今臺灣、中國所使用的許多法律

73 參見王泰升，台灣法律史上的原住民族：作為特殊的人群、領域與法文化，臺大法學論叢，44卷4期，頁1644-1670（2015年）。

74 較詳細的論述，參見王泰升（註14），頁78、88。

術語，即日本於明治時期為引進近代西方法/現代法，參考以漢字書寫的古代典籍所創造的。今日臺灣法之採取美國制度，有時是透過引進日本早已繼受美國法制的相關規定來達成，例如臺灣刑事訴訟法為了向美國法靠攏，引進日本的「改良式當事人進行主義」⁷⁵。至於顏文指出「臺灣繼受的西方法，雖然常常也說是現代法，……但是從歐陸法學/法律的角度來看，其實是羅馬法，是古代法。」已超出我的學識能力，在此無法回應，須待拙文所言的比較法史研究者深入處理該等議題。

不過，顏文所期許的超越實證立法的文字或意義而探究法律史，一直是我努力的目標。顏厥安2000年時即表示，我所做的臺灣法律史研究，「較不重視物質條件所形成之長期結構作用力的問題。因此諸如地理、人口、生產、貨幣、交易、商品、交通等等概念及其計量方法，並非王教授研究的重點」⁷⁶。於今顏文亦指出：「透過政權（regime）所刻意創設的實證立法，……僅僅是宣示公布的文字或其意義而已，如果不能搭配或轉化為社會經濟現實，……實證法也僅是空話。而這種搭配或轉化，就是透過法的規範性（legal normativity）來達成。而法的規範性可以有不同的類型。例如……「指令式」（imperative）的規範性；……「利潤/誘因」型（profitable/incentive）的規範性；……「權利型」（right-based）的規範性（我有權要求你們……）」。經過20餘年的學術累積，我終於透過2017年出版的《去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型》，稍微「補正」了缺失。

這本以臺灣福佬話「去法院相告」作為書名的學術作品，欲探究日本政權頒佈的有關法院、民刑事項的法律規範，是否或在怎樣的程度對人民的生活產生指引作用（抑或僅為空話）？哪些不同層

75 參見王泰升（註14），頁199-200。

76 顏厥安（註12），頁25。

面的因素造就這樣的結果？該書先確認日本統治當局為減少殖民地司法經費支出，所制定的法規僅導入一部分的現代性。接著將日治時期臺北地方法院48,338件民事判決、82,407件刑事判決的當事人各項資料，以及訴訟的年代、類型、參與者、結果等作為變數，進行編碼後為交叉分析。這項兼顧量化及質性之研究指出，在前揭法制上的侷限下，臺灣人依社會階層別、地域別、性別等，透過不同的使用法院經驗，其司法正義觀有不同程度的轉變。亦即，較易發生現代商業糾紛的商人階層，較傾向於使用法院，感受到「判調分立」。住所距法院遙遠者，雖為避免舟車勞頓等而較常聘請律師，但因而須負擔高額律師費用，導致較少使用法院，尤以經濟弱勢者為然，從而少有機會接觸律師而體會「審辯分立」。民事案件當事人絕大多數為男性，故其較有機會改採現代司法觀，但也不乏女性將事涉經濟利益的家族紛爭帶入法院而受現代司法影響。在大多數刑案未進入法院的情形下，日治後期法院內刑案近三成是以未曾與檢察官在公判庭對辯的方式終結，故一般人難以理解「審檢辯分立」下檢察官的角色。在整個論述過程，除了法院判決等，還使用多種材料，包括當時的報紙、時人的日記、臺北州各市郡的人口數及產業狀況圖、鐵公路交通路線圖等⁷⁷。

上述的研究經歷，正說明臺灣法律史有學科化的必要。如拙文所言，我在踏入學術界時，已具有與社會現實最接近的執業律師經驗，故何嘗不想探究各種法律規範在社會上的實踐呢？但是法制度面向若不先了解，如何洞悉其在社會生活上的運作狀況？不知實況，又如何思考法律規範與政經社文諸條件之間錯綜複雜的關係？學術研究經常需要長時間的累積，才能夠做出成績。這本《去法院相告》即立足於從1990年代以來20餘年有關日治時期法律史的研究成果，方能以新史料之發現及完成整編為契機，嘗試做超越法規範

77 參見王泰升（註28），頁11-162。

史的法社會學式實證研究⁷⁸。因此臺灣法律史之學科化的另一層意義，在於讓有意探究這方面議題的新進學者，能夠「婉拒」資深學者善意的建議：「怎麼不多研究一些現在的實證法？」、「研究中國的法律史，比較有機會在國際上發表啊！」唯有臺灣法律史被認為「也是」一門學科，才不會讓個別的研究者，獨自承受「做一些臺灣法律史以外的研究」之壓力，而有機會經由10年、20年的累積，做出自始就想做的研究。

伍、結語：期待其他的評論

原先在籌辦「台灣法律史二十年」研討會時，對於我須再次談臺灣法律史的意義及研究方法或取徑，心裡有點無奈，甚或排斥，最終決定賦予一些新的意義，故在「自我交代」研究過程後，表達「這是大家的事」之意，亦即應學科化。按之前1997年《台灣法律史的建立》的〈導論〉已曾就這個主題做過表述，2001年《台灣法律史概論》第一章再簡述之，2006年《追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究》則於敘述臺灣法律史上一百件事之後，特別開闢「第二部：法律史的研究方法」詳論之，連怎麼搜尋參考資料都提過，也該「事不過三」了吧。令人欣慰的是，這次的確有所不同，由於中研院法律所期刊提供的評論及回應的機制，故得以跟其他研究者對話與交流，誠受益良多也。

2017年年底在「台灣法律史二十年」國際研討會上發表時，聽眾對於如何將過去的法經驗事實，運用於法制訂或法適用時的法律

⁷⁸ 該書於2018年12月21日獲頒「第七屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」。參見中央研究院學術諮詢總會與學術及儀器事務處，http://daais.sinica.edu.tw/chinese/pro_sma_ceremony.php?yearId=7（最後瀏覽日：2019年2月12日）。

論證，提出若干質疑，拙文因而做了不少補充。可惜前述三位評論人很少觸及這個議題，僅陳文稍做引介。目前拙文對此議題所表達的見解，可能還是有自以為寫得清楚但別人仍不完全明瞭的地方，或者確有不自知的盲點，乃至需要再斟酌之處。期待論者不拘形式、不管何時，能不吝惠賜卓見，因為這是我目前仍在思考中的議題，也將會是臺灣法律史累積的研究資源，如何可以成功地轉化臺灣法學知識，甚至影響立法與司法及行政上實務工作的關鍵。

參考文獻

1. 中文部分

- 王泰升（2001），台灣法律史概論，臺北：元照。
- （2006），撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，2版，頁57-96，臺北：自版。
- （2006），日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，頁99-158，臺北：自版。
- （2006），台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，頁183-255，臺北：自版。
- （2007），台灣法律文化中的日本因素：以司法層面為例，政大法學評論，95期，頁55-89。
- （2007），清末及民國時代中國與西式法院的初次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁105-162。
- （2009），台灣法律史概論，3版，臺北：元照。
- （2009），國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228。
- （2010），來回穿梭於法律與歷史之間，新史學，21卷3期，頁187-232。
- （2010），具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，臺北：自版。
- （2011），中華民國百年法學發展史，收於：國立政治大學人文中心編，中華民國發展史（一）：學術發展（上冊），頁287-315，臺北：國立政治大學、聯經。
- （2014），台灣日治時期的法律改革，修訂2版，臺北：聯

經。

- （2014），西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（八）（上冊），頁49-114，臺北：中央研究院法律學研究所。
- （2015），台灣法律史上的原住民族：作為特殊的人群、領域與法文化，臺大法學論叢，44卷4期，頁1639-1704。
- （2015），臺灣司法官社群文化中的中國因素——從清末民國時代中國追溯起，政大法學評論，142期，頁1-46。
- （2015），臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，臺北：中央研究院臺灣史研究所、臺大出版中心。
- （2016），土地、人民、法律與歷史，收於：王泰升、薛化元、黃世杰編，追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究，3版，頁260-273，臺北：五南。
- （2017），去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型，修訂版，臺北：臺大出版中心。
- （2017），台灣法律史概論，5版，臺北：元照。
- （2017），具有「彈性」的人文思考，中央研究院、國立清華大學、國立交通大學新進研究人員交流會，中央研究院主辦，2017年6月9-10日。
- （2017），換個角度看台灣的法律史，國立臺灣大學跨領域交流會（第17次），國立臺灣大學法律學院暨社會科學院主辦，2017年12月26日。
- （2018），人文社會取向的法學，交大法學暨跨領域講座，國立交通大學科技法律學院主辦，2018年4月18日。
- （2018），換個角度看台灣的法律史：從台灣學出發，「台灣學在台大」演講，國立臺灣大學臺灣文學研究所暨臺灣研究學程主辦，2018年5月18日。
- （2018），人文社會取向的法學，2018年科技部法學研習營，中央研究院法律學研究所、國立中興大學法律學系主辦，

2018年11月30日。

王泰升、堯嘉寧、陳韻如（2004），戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話，法制史研究，5期，頁255-325。

王泰升、曾文亮（2005），二十世紀台北律師公會會史，臺北：台北律師公會。

王泰升、曾文亮、吳俊瑩（2015），論清朝地方衙門審案機制的運作：以《淡新檔案》為中心，中央研究院歷史語言研究所集刊，86本2分，頁421-469。

吳豪人（2017），殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像，臺北：臺大出版中心。

吳聰敏（2018），改朝換代與財富移轉，2018年度研討會：台灣戰後初期的財富重分配，台灣制度與經濟史學會、國立臺灣大學經濟學系、國立臺灣大學法律學院法律與社會研究中心合辦，2018年12月15日。

李維倫（2007），日治時期台灣笞刑之研究：以竊盜罪為例，國立臺灣大學經濟學研究所碩士論文。

淺古弘著，堯嘉寧譯（2009），歷史分析與法：日治時期的台灣法院紀錄史料，收於：王泰升編，跨界的日治法院檔案研究，頁329-346，臺北：元照。

盛清沂（1980），明鄭的內治，收於：黃富三、曹永和編，臺灣史論叢（一），頁125-161，臺北：眾文。

陳韻如（2004），帝國的盡頭——淡新檔案中的姦拐故事與申冤者，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

——（2018），《淡新檔案》中姦拐案件：法律傳統的重新檢視，臺灣史研究，25卷4期，頁21-73。

堯嘉寧（2005），官府中的紛爭解決——以淡新檔案觀察相當於今日新竹市之區域之案件，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

黃靜嘉（2002），春帆樓下晚濤急：日本對臺灣殖民統治及其影響，臺北：臺灣商務。

楊崇森（2014），遨遊美國法——美國法之源流與民刑法之運作，新北：國立臺北大學、華藝學術出版社。

劉恆姣（2019），戰後臺灣的「黨化司法」——1990年代之前國民黨對司法人事的制度性掌控及其後續影響，中研院法學期刊，24期，頁1-86。

韓忠謨（1977），法學緒論，6版，臺北：自版。

顏厥安（2000），法律史研究中的理論問題——評王泰升：《台灣法律史的建立》〈導論〉部分，收於：王泰升、沈靜萍、陳鈺雄編，台灣法律史研究的方法，頁17-31，臺北：學林。

2. 外文部分

(1) 日文

王泰升著，鈴木賢、松田恵美子、西英昭、黃詩淳、陳宛妤、松井直之、阿部由理香譯（2014），台灣法における日本の要素，臺北：臺大出版中心。

吳豪人（2000），「台灣法史」の可能性：法社会史的・法思想史的試論，京都大学大学院法学研究科博士論文。

後藤武秀（2005），台灣領有初期における民訴不受理政策 — 明治三二年律令第一號の制定と判決原本から見た運用状況 — ，小野幸二、野口明宏、笠原俊宏編，市民法と企業法の現在と展望，頁245-268，東京：八千代。

——（2009），台灣法の歴史と思想，京都：法律文化社。

蔡秀卿、王泰升編（2016），台灣法入門，京都：法律文化社。

西英昭（2009），『臺灣私法』の成立過程：テキストの層位学的分析を中心に，福岡：九州大学出版会。

(2)西文

Hooker, M. B. 1975. *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press.

Wang, Tay-sheng. 1997. Chapter 4: Taiwan. Pp. 124-161 in *Asian Legal Systems: Law, Society and Pluralism in East Asia*, edited by Poh-Ling Tan. Sydney: Butterworths.

———. 1999. The Impact of Modern Western Law on the Chinese in Taiwan, translated by Sean Cooney. *Australian Journal of Asian Law* 1:194-220.